

1501907-08.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... em porções, além de anotações de tráfico. Os réus confessaram o tráfico. A acusada disse que receberia R\$500,00 para encontrar com o réu e levar as drogas até o ponto de drogas. O réu disse que ganhava R\$200,00 para levar a acusada até o ponto de tráfico. Não conhecia os réus anteriormente. Narrou que em poder do réu havia R\$150,00.

No mesmo sentido foi o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501907-08.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501907-08.2022.8.26.0537 Controle nº 1449/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANUSA NERES DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

WESLEY ANDRADE DE ALMEIDA SANTOS e VANUSA NERES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, c.c. o art. 29 do Código Penal, porque no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 10:30 horas, na Avenida Chico Mendes, altura do n.º 790, Bairro Serraria, previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, adquiriram, traziam consigo, guardavam e transportavam, para consumo de terceiros, maconha, cocaína, "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

As prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas na audiência de custódia (fls. 54/57), tendo sido reapreciadas em 27.10.22 e mantidas (fls. 114). Foi apresentada defesa prévia (fls. 86/93), sendo recebida a denúncia em 27.10.22

(fls. 113/115). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Os réus foram interrogados no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, que seja considerada a confissão judicial da acusada e reincidência dos réus, com fixação de regime fechado e perdimento da motocicleta apreendida.

O defensor dos acusados requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação, a fixação da pena no mínimo, compensação das confissões com a reincidência dos réus e fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O réu Wesley, na fase policial, confessou a prática do crime (fls. 14). Disse que estava precisando de dinheiro, aceitou trabalhar para o tráfico, fazendo o transporte de drogas para um homem cujo nome não sabia informar. Relatou que foi orientado aguardar com a motocicleta na esquina da Rua Chico Mendes, próximo a uma padaria, por uma mulher que se chamava Vanusa, a qual estaria portando uma bolsa verde e nesta as drogas que ele deveria transportar até outro endereço. Afirmou que receberia R\$ 200,00 para fazer o transporte das drogas. Disse que não poderia informar para quem e onde entregaria as drogas. Falou e que era a primeira vez que fazia esse tipo de trabalho e que conheceu Vanusa na manhã daquele dia.

Em juízo, negou ter praticado o crime. Narrou que a ré pediu uma carona, mas não sabia que ela estava com drogas. Estava dirigindo a moto e deu uma carona, porque a ré mora perto de onde está construindo a sua casa. Machucou o pé quando caiu da moto. Informou que está há dois anos na rua em condicional, trabalhou registrado, mas foi demitido. Falou que depois disso estava trabalhando entregando pizza e marmitex. Tem condenação por roubo. Não conhecia os policiais. Narrou que não é usuário de drogas.

A acusada Vanusa também confessou o crime na fase policial (fls. 15). Disse que estava desempregada, precisava sustentar os quatro filhos e por isso aceitou transportar as drogas para um homem, cujo nome não sabia informar, nem onde poderia ser localizado. Relatou que naquela manhã, próximo ao largo do Serraria, recebeu uma mochila com drogas, não sabendo a quantidade, com a orientação de ir até a Rua Chico Mendes, onde um homem a aguardava com em uma motocicleta para leva-la a outro local, que afirmou desconhecer, onde as entregaria. Narrou que ao chegar à Rua Chico Mendes embarcou na motocicleta do réu Wesley e seguiram até o ponto de entrega. Falou que no trajeto cruzaram com uma viatura da Polícia Militar, quando Wesley acelerou, tentando fugir, porém foram alcançados e presos. Declarou que receberia R\$ 500,00 pelo transporte das drogas.

Em juízo, narrou que um conhecido pediu para entregar a bolsa pra um motoqueiro. O réu apareceu, falou para subir na moto, seguiram e deram de "cara" com os policiais. Conhecia o réu de vista. Sabia que tinha drogas na bolsa e ia receber R\$500,00. Disse que aceitou, porque estava precisando de dinheiro para comprar remédios para a sua mãe, que tem Parkinson. Tem uma condenação por tráfico anterior. Trabalhava cuidando de crianças. Está arrependida.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 11 e 13), disseram que avistaram os acusados em uma motocicleta Honda CG Fan-1125, e que quando se aproximaram com a viatura o condutor empreendeu em fuga. Relataram que seguiram os réus por alguns metros, até que conseguiram abordá-los. Narraram que a ré trazia uma mochila verde nas costas, na qual apreenderam drogas e algumas folhas de papel manuscritas, com anotações referentes ao tráfico. Afirmaram que a ré confessou que receberia R\$ 500,00 para levar a mochila com as drogas até próximo de onde foram abordados, onde a entregaria para Wesley. Falaram que o réu conduzia a motocicleta e informou que sabia que a ré estava transportando as drogas. Narrou que a partir daquele ponto ele mesmo iria transporta-las até o destino final, porém, não quis informar qual era o local, nem para quem as drogas seriam entregues.

Wilson (policial), em juízo, narrou que o réu dirigia a moto e a acusada estava na

garupa, que tentaram fugir, mas foram abordados. A ré estava com bolsa feminina e a jogou no chão, sendo que no interior desta havia drogas, divididas em porções, além de anotações de tráfico. Os réus confessaram o tráfico. A acusada disse que receberia R\$500,00 para encontrar com o réu e levar as drogas até o ponto de drogas. O réu disse que ganhava R\$200,00 para levar a acusada até o ponto de tráfico. Não conhecia os réus anteriormente. Narrou que em poder do réu havia R\$150,00.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Diego. Acrescentou que a ocorrência foi gravada. Disse que a ré não dispensou a bolsa.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

“PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação” (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24). Ademais, os acusados disseram que não conheciam os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-los indevidamente.

A quantidade (fls. 06 – 448 porções de maconha, 200 invólucros de cocaína e 300 pedras de “crack”) e a variedade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e “crack”), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuários e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que os acusados confessaram na fase policial e a ré também em juízo, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teriam como adquirir essa quantidade e variedade se não fossem traficantes.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciados pelas condutas de adquirir, trazer consigo, guardar e transportar. Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Segundo a jurisprudência:

“Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização” (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

“Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio” (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

A negativa judicial do réu está isolada nos autos, posto que disse que a acusada pediu carona, enquanto esta afirmou que aquele a mandou subir na moto, pelo que a confissão extrajudicial dele foi corroborada pela prova oral produzida.

Apesar das ponderações da defesa em razão da grande quantidade de ocorrências que atendem, nem sempre é possível os policiais se recordarem de todos os detalhes. Porém, foram uníssonos no sentido de que as drogas estavam em poder dos réus, os quais confessaram o tráfico na fase policial e a acusada em juízo.

Quanto à alegação do réu que ficou lesionado é desmentida pelo laudo de exame de corpo de delito com resultado negativo (fls. 141).

Desta forma, impõe-se a condenação dos réus, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 08/10) e laudo definitivo (fls. 132/134).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada aos acusados, que segundo consta dos autos, o réu é triplamente reincidente por roubo (fls. 46 – proc. 13600-70.2016 – em cumprimento de pena – fls. 97; fls. 46/47 – proc. 22180-32.2011 – penas comutadas – fls. 42; fls. 147/148 – proc. 3009236-28.2013 – penas comutadas – fls. 42), e a ré é reincidente específica (fls. 34 – proc. 12188-16.2016 – pena julgada extinta em 27.04.21 – fls. 35).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que “a lei regulará a individualização da pena” e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)".

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico, em razão da quantidade média de drogas (fls. 06 - 448 porções de maconha, 200 invólucros de cocaína e 300 pedras de "crack", já que pequena quantidade em Diadema é inferior a 100 porções), em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica dos acusados.

Compenso a reincidência dos réus e as confissões, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito recente decisão do STJ:

Processo

AgRg no REsp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Os acusados não fazem jus à redução do art. 33, §4.º, porque são reincidentes e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não são primários) que são

cumulativos, além de se dedicarem a atividades criminosas, já que o réu possui três condenações por roubo e a acusada uma condenação anterior por tráfico, além de não provarem ocupação lícita, nem mesmo eventual.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois o acusado é triplamente reincidente por roubo (fls. 46 – proc. 13600-70.2016 – em cumprimento de pena – fls. 97; fls. 46/47 – proc. 22180-32.2011 – penas comutadas – fls. 42; fls. 147/148 – proc. 3009236-28.2013 – penas comutadas – fls. 42) e a acusada é reincidente específica (fls. 34 – proc. 12188-16.2016 – pena julgada extinta em 27.04.21 – fls. 35), o que denota personalidades voltada para crimes, uma vez que sequer provaram possuir ocupação lícita, o que demonstra que o tráfico é o meio de vida de ambos e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis", diante do montante da pena.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (presos em 12.09.22, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 11.01.25).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO WESLEY ANDRADE DE ALMEIDA SANTOS e VANUSA NERES DE OLIVEIRA à pena de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se acharem incursos no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que os réu foram presos em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que os vincule ao distrito da culpa (não comprovaram ocupação lícita nem residência fixa) e é incabível qualquer benefício, recomendem-se na prisão em que se encontram.

Custas "ex lege" (Lei n.º 11.608/03).

Quanto à motocicleta marca Honda CG 125 FAN KS, ano/modelo 2011, cor preta, de placas EQR6B00, apreendida (fls. 06), não é caso de determinar o perdimento em favor da União, (art. 63 da Lei n.º 11343/06), uma vez que pertence a terceiro (fls. 06), bem como que não é produto ou proveito do crime, não se justificando a perda do bem em virtude de uma única atividade ilícita demonstrada. A liberação do motociclo poderá ser concedida após comprovação da propriedade. Oficie-se, após trânsito em julgado, que não interessa mais ao feito e que decorrido o prazo do art. 122 do CPP pode ser dado o destino pertinente. A liberação depende de

demonstração da propriedade.

Em relação à bolsa da marca "Langmu Supply" e às 3 (três) folhas de papel pautadas e manuscritas, apreendidos (fls. 06) e já periciados (fls. 129/131 - bolsa; fls. 135/136 - folhas de papel), tendo em vista que não possuem valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessam mais aos autos podendo ser eliminados. Transitada esta em julgado, lancem-se o nome dos acusados no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 58) e efetuem-se os cálculos das multas, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 23 de novembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA